

1500491-31.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080139/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23804707 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2080139 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN JOÃO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-31.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080139/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23804707 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2080139 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN JOÃO GABRIEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ADRIAN JOÃO GABRIEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e com o artigo 29 do Código Penal.

Notificado (fls. 190), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 203/204).

A denúncia foi recebida em 25 de maio de 2022 (fls. 1711/1712) e o acusado foi citado (fls. 1753).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 1778/1779).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 1783/1788).

A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da prova decorrente de irregular atuação policial. No mérito, pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da reprimenda no mínimo legal e aplicação de benesses legais (fls. 1792/1807).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/19), boletim de ocorrência (fls. 20/25), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), documento de fls. 62, fotografias (fls. 65/70), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/117), laudos periciais (fls. 118/124 e 205/1704) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos e aduziu que parou no local para dividir um baseado com o adolescente, que já estava fumando, quando foram abordados. Em sua posse havia dois celulares, o seu e o de sua esposa, e R\$ 126,00. Com o menor foram encontrados quatro pinos de cocaína e o baseado que estavam fumando. Ato contínuo, os policiais dirigiram-se a local próximo, retornaram com os entorpecentes e afirmaram que iriam à sua casa. Autorizou a entrada deles no imóvel, pois ali só havia um baseado e um pino de cocaína, todavia permaneceu na viatura. Na delegacia lhe foram mostrados outros entorpecentes que não eram seus. Não é proprietário de um veículo Celta, não estava com a chave dele, tampouco sabe informar se referida chave foi encontrada no chão ou com o adolescente.

O adolescente R. contou que estava fumando um baseado quando encontrou o réu e o convidou para fazerem uso da droga juntos. Tinha quatro porções de cocaína, localizadas pelos policiais durante a revista. Adrian não estava com nenhum entorpecente. Não viu um veículo Celta nem se os policiais encontraram droga nele ou se o réu estava com a chave.

O policial civil Paulo relatou que recebeu informações de que um rapaz (cujas características físicas e vestimentas foram descritas) estaria vendendo drogas em uma esquina conhecida por ser ponto de tráfico e mantinha os entorpecentes armazenados em um veículo que ficava estacionado nas imediações. Ao chegar no local indicado, visualizou dois indivíduos. Um deles era o réu, conhecido dos meios policiais, que possuía as características e vestes indicadas. Localizou dinheiro e a chave de um veículo com o acusado e quatro pinos de cocaína com o adolescente que o acompanhava. Em posse da chave identificou o carro do réu estacionado próximo dali. Seu colega efetivou busca no automóvel e nele encontrou diversas porções grandes de "crack" e cocaína, além de aproximadamente R\$ 400,00. Adrian informou que havia mais drogas em sua casa e autorizou o ingresso no imóvel, sendo localizadas no quarto três porções de maconha, vários eppendorfs vazios, um simulacro de arma de fogo e produtos utilizados na confecção de entorpecente chamado "loló" ou "lança". Não realizou campana anterior para averiguar os fatos, vez que prontamente identificou Adrian ao chegar ao local, e não pediu sua autorização para a busca no carro.

No mesmo sentido, em linhas gerais, as declarações do policial civil Bruno, que asseverou ter sido o responsável pela revista no veículo.

Pois bem.

Inicialmente, não se vislumbra ilegalidade na ação policial, como sustentado pela defesa. Os policiais civis declararam que receberam informações sobre a ocorrência de tráfico em esquina conhecida como ponto de venda de entorpecentes, nas quais eram detalhadas as características físicas do traficante, a roupa que ele usava e a informação de que as drogas ficavam armazenadas em um carro estacionado nas proximidades. O réu estava no local e batia com a descrição efetuada. Ele tinha em sua posse a chave de um veículo e estava acompanhado de um adolescente, com o qual foram encontrados 4 pinos de cocaína. Nesse contexto, era prescindível a autorização do réu para busca no veículo ou ingresso no imóvel, já que as circunstâncias que antecederam a atuação policial denotavam fundadas suspeitas de que o acusado estivesse em situação de flagrância, confirmada com as buscas veicular e domiciliar.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. ... 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem ...” (STJ - AgRg no HC: 635303 SP 2020/0343358-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

As provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

Ouvido em sede policial (fls. 18/19) o acusado, a despeito de negar o tráfico, afirmou que estava com a chave do automóvel do menor porque o havia abastecido e que tinha conhecimento de que os entorpecentes encontrados pelos policiais estavam armazenados no carro, atribuindo-os ao adolescente.

Em seu interrogatório judicial, como se viu, alterou sua versão e aduziu que está sendo falsamente incriminado. Alegou, em suma, que não sabia de drogas, não tinha nenhuma chave com ele e que os policiais se ausentaram brevemente do local da abordagem e depois apareceram com as substâncias ilícitas.

O adolescente, por sua vez, apresentou versões contraditórias. À autoridade policial (fls. 16), admitiu a traficância e avocou para si a propriedade do veículo Celta e de todos os entorpecentes, inclusive aqueles localizados na casa de Adrian. Em juízo, negou até saber sobre a existência de algum carro estacionado nas proximidades.

As alegações de ambos foram infirmadas pelos demais elementos de prova.

Conforme se vislumbra de fls. 35, o automóvel Celta no qual estavam armazenados os entorpecentes foi fabricado no ano de 2005, dado que, aliado ao encontro da chave com Adrian e às mensagens trocadas entre ele e o funcionário do estabelecimento “Pedrinho Auto Peças” (fls. 1458/1460) – nas quais o réu procura por farol e vidro para um Celta ano 2005/2006 -, denotam que era ele o dono, ou ao menos o possuidor, do referido automóvel.

As informações acima convergem com os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, afastando a pueril alegação de Adrian de flagrante forjado.

A destinação para entrega a terceiros restou demonstrada pela dinâmica da abordagem em consonância com as informações que a motivaram, bem como pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, além de apetrechos – eppendorfs vazios, latas de solvente e balança de precisão (fls. 28/29) - para individualização de porções para venda e mistura de drogas. Somem-se a isso o encontro de dinheiro sem comprovação de origem lícita e as mensagens extraídas do celular do acusado, que corroboram sua atividade no comércio espúrio, em especial as constantes de fls. 311 (mais 338/339 e 1590/1591), 327, 493/494, 1387, 1464 e 1537.

Assim, não há como acolher as teses defensivas, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado na denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido (“crack”), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade e a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Assim, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, inaplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o teor das mensagens encontradas em seu celular, aliado aos seus antecedentes infracionais e à prisão anterior pelo mesmo delito (fls. 174/175), demonstram que o acusado se dedicava a tal atividade criminosa.

Presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o crime envolveu adolescente (fls. 62), ao que majoro a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Considerando-se os motivos esposados na primeira e na terceira fases, a reprimenda deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz

natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a

ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, o acusado ADRIAN JOÃO GABRIEL, qualificado nos autos, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois permaneceu preso no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram a sua custódia cautelar (fls. 83/84), notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e valores apreendidos em favor da União.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

Por fim, considerando o conteúdo de imagens envolvendo menor de idade, determino seja o laudo pericial de fls. 205/1704 colocado sob sigilo, liberando-se seu acesso apenas às partes. Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para análise de eventual prática do crime previsto no artigo 241-B, ECA e adoção das providências cabíveis.

P.I.C.

Jaú, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA